

1024688-83.2019.8.26.0053

Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa

Assunto: Violação aos Princípios Administrativos

Magistrado: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... judicial, a indivíduo preso por tráfico de drogas.

O bem restituído foi apreendido por decisão judicial, proferida em 3 de maio de 2018, ordem dada pela MM. Juíza de Direito do Departamento de Inquéritos policiais, atendendo requerimento de autoridade policial e com parecer favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO. Referida ordem foi executada em 16 de maio de 2018.

Aduz que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80 - 5º andar, São Paulo-SP - cep 01501-908

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1024688-83.2019.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1024688-83.2019.8.26.0053

Classe - Assunto:

Ação Civil de Improbidade Administrativa - Violação aos Princípios Administrativos

Litisconsorte Ativo e Requerente:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Requerido:

Amadeu Ricardo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação cível em face de AMADEU RICARDO DOS SANTOS e de VINÍCIUS BAIRRÃO ABRÃO MIGUEL, feito que segue o procedimento comum ordinário e a Lei 8.429/92.

Alegou, em suma, foi instaurado inquérito civil para apuração de ato de improbidade administrativa praticado pelo réu AMADEU RICARDO DOS SANTOS, Delegado de Polícia, presidiu inquérito policial, que resultou nos pedidos de prisão e busca e apreensão em desfavor de Frederico Gustavo Troiano Buhrer, e que o réu que teria autorizado, por despacho de próprio punho, a restituição de bens de expressivo valor econômico, descrito como sendo o veículo automotor marca Mercedes Benz, modelo AMG GLE43, avaliado em R\$ 499.999,00, apreendidos por determinação judicial, a indivíduo preso por tráfico de drogas.

O bem restituído foi apreendido por decisão judicial, proferida em 3 de maio de

2018, ordem dada pela MM. Juíza de Direito do Departamento de Inquéritos policiais, atendendo requerimento de autoridade policial e com parecer favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO. Referida ordem foi executada em 16 de maio de 2018.

Aduz que a restituição do veículo automotor se deu a partir de despacho AMADEU RICARDO DOS SANTOS em petição apresentada pelo réu VINÍCIUS BAIRRÃO ABRÃO MIGUEL.

Ainda, noticia que dias depois, o referido delegado de polícia promoveu a restituição de cartões bancários, talões de cheques e documentos bancários em nome de Frederico Gustavo Troiano Buhner.

Defende que a conduta dolosa adotada pelos réus decorre do fato de que as "decisões" foram proferida pelo réu AMADEU RICARDO DOS SANTOS no mesmo dia em que as petições foram apresentadas, sem qualquer fundamentação e sem competência para a liberação de bens apreendidos.

Aduz que os réus praticaram condutas que violara princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, em conluio fraudulento,

Ao final, pediu a procedência da para condenar a condenação do réu AMADEU RICARDO DOS SANTOS, como incurso no artigo 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/92, para aplicação das penas de ressarcimento integral do dano a ser calculado em fase de liquidação judicial, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Ainda, postulou a condenação do réu VINÍCIUS BAIRRÃO ABRÃO MIGUEL, como incurso no artigo 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/92, para aplicação das penas de suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Devidamente notificados, os réus apresentou manifestação escrita, arguindo preliminares, e, no mérito, suas irresponsabilidades.

Decisão fundamentada recebeu a petição inicial apenas em relação ao réu AMADEU RICARDO DOS SANTOS., decisão confirmada em recurso de agravo de instrumento e em recurso especial.

AMADEU RICARDO DOS SANTOS defendeu a ausência de elementos probatórios que possam caracterizar o ato de improbidade administrativa, mormente porque inexistente o aventado conluio doloso entre os requeridos. Sustentou que não havia ordem judicial para a apreensão dos bens liberados e que se cumpriu o disposto no artigo 120 do CPP. Aduziu sua boa-fé, pedindo a rejeição liminar da inicial.

O autor manifestou-se em réplica.

Instados a especificarem provas, nada de relevante restou postulado.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a matéria de fato tratada nos autos está suficientemente instruída pela prova documental acostada na fase postulatória e que a controvérsia dos auso

possui natureza exclusivamente jurídica, o feito comporta julgamento antecipado de mérito.

No mérito, de rigor a improcedência dos pedidos.

A questão candente a ser solucionada nos autos está centrada na existência de ato de improbidade administrativa, pelo descumprimento de princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, em conluio fraudulento.

Inicialmente, a ideia da existência de um conluio fraudulento entre o réu AMADEU RICARDO DOS SANTOS e VINÍCIUS BAIRRÃO ABRÃO MIGUEL perdeu objeto diante da posicionamento adotado pelo Juízo, confirmado por instâncias superiores, no sentido de que a atuação do patrono de investigado se deu no exercício regular de sua profissão e do mandato que lhe foi outorgado. E esta questão não será renovada em sentença, até porque atingida pela coisa julgada.

Resta a análise da conduta do delegado de polícia que liberou bens apreendidos por força de mandado de prisão e de busca e apreensão, sem autorização judicial.

O réu AMADEU justifica sua conduta com base em permissivo no artigo 120 do Código de Processo Penal, que possui seguinte redação:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 10 Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5o Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. (grifo nosso)

Pois bem. Se é incontroverso que a autoridade policial tem competência para a restituição de bens apreendidos, quando inexistente dúvidas quanto ao direito do reclamante, é fato que o procedimento adotado para a restituição do bens deve observar o Código de Processo Penal.

O § 3º do mesmo artigo é claro em afirmar que a restituição de bens deve ser precedida da oitiva do MINISTÉRIO PÚBLICO, providência que não foi observada.

Mas não é só. Temos que observar que a busca e apreensão se deu em inquérito policial para apuração de condutas tipificadas na Lei nº 11.343/06, que traz disposições específicas à apreensão de bens e a restituição deles, disposições que eram do conhecimento do réu.

Dispunha o CAPÍTULO IV - DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO, com redação anterior a Lei nº 13.840/19:

Art. 60. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público,

havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§1º - Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca da origem lícita do produto, bem ou valor objeto da decisão.

§2º - Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

§3º - Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.

§4º - A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações.

Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o interesse público ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorização do juízo competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso indevido, na atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.

§1º - Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

§2º - Feita a apreensão a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.

§3º - Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo, em caráter cautelar, a conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§4º - Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.

§5º - Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4º deste artigo, o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§6º - Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em

apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.

§7º - Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, cientificará a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.

§8º - Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.

§9º - Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada, até o final da ação penal respectiva, quando será transferida ao Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3º deste artigo.

§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 4º deste artigo, recaiando a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da autoridade de polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§1º - Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

§2º - Compete à Senad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União.

§3º - A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 2º deste artigo.

§4º - Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

Não precisa ser um gênio para se perceber que a apreensão e a liberação de bens apreendidos, no curso de investigação por tráfico de entorpecentes, demanda maior cuidado do que a singela autorização genérica trazida pelo Código de Processo Penal, especialmente quanto a especificidade de que a liberação de bens depende de decisão judicial, após prévia oitiva do MINISTÉRIO PÚBLICO, após certeza de que os bens apreendidos tem ou não relação com o tráfico de entorpecentes e tem origem lícita

Ainda que o acúmulo de funções e de tarefas seja uma realidade em qualquer Delegacia de Polícia, não entendo como razoável que a conduta dolosa adotada pelo réu seja passível de desconsideração em face ao potencial prejuízo para as investigações criminais.

Enfim, a despeito do diligente trabalho da defesa do réu, entendo que o proceder dele não deve passar impune, merecendo justa reprovação desse Juízo. Afinal, configuram atos de improbidade administrativa na definição do artigo 1º, "caput", da Lei nº 8.429/92, in verbis:

Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de

empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Ainda, o réu deve ser enquadrado na condição de agente público, na forma do disposto no artigo 2º:

Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Passando ao enquadramento legal, impõe-se o enquadramento das condutas praticadas pelo réu no artigo 11 da Lei de Improbidade, pois é certo que o réu praticou conduta em manifesta contrariedade aos preceitos da Lei nº 11.343/09, com manifesto prejuízo para as investigações criminais e em flagrante violação a princípios e deveres inerentes ao cargo que ocupa.

Derradeiramente, das sanções postulada pelo autor, apenas entendo que não há fundamento para se aplicar apenas a pena de ressarcimento os cofres públicos dos valores dos bens extraviados ou perecidos, pois ausente certeza de que os bens apreendidos seriam revertidos em dinheiro ou incorporados ao patrimônio da UNIÃO.

Nestes termos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e condeno o réu AMADEU RICARDO DOS SANTOS por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, impondo-lhe as penas de: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por dez anos; c) pagamento de multa civil no valor equivalente a 100 vezes a remuneração integral e final dele, devidamente corrigida pela Tabela Prática para a Atualização dos Débitos Judiciais (INPC) do TJ/SP a partir da distribuição da ação; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

Deixo de condenar o réu em honorários advocatícios por me filiar ao entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por questão simetria, não cabe condenação do réu em honorários advocatícios. Cito precedente:

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DE CULPA E DOLO GENÉRICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário). 3. Cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes. Precedentes do STJ. 4. Modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 5. É firme a jurisprudência da Primeira Seção no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil pública

ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Resp 1346571 /PR, j. Em 5.9.2013)

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA